

1500402-10.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MENDONÇA CARIBE

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra RAFAEL MENDONÇA CARIBE, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500402-10.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500402-10.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MENDONÇA CARIBE

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra RAFAEL MENDONÇA CARIBE, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a pretensa incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma.

Sustenta a denúncia que, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 09h20, na Avenida dos Mariscos, nº 500, nas dependências do Centro de Progressão Penal desta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 27 porções de maconha, com peso total bruto de 48g gramas, conforme Auto de Exibição/Apreensão de fls. 38 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 36/37.

Narra que o acusado cumpre pena privativa de liberdade no Centro de Progressão Penal de Mongaguá, e querendo praticar a mercancia ilícita de entorpecente, trazia consigo a supramencionada substância. Na data dos fatos, durante a revista pessoal dos reeducandos, os agentes penitenciários encontraram em uma sacola plástica que

estava nas mãos do acusado, 27 porções a granel de maconha. Em razão destes fatos, o acusado foi conduzido ao Distrito para a lavratura da ocorrência.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 63/65).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou defesa prévia (fls. 71/72).

Lauda pericial a fls. 93/95.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado confessa ter sido surpreendido com a droga na mão, mas que era destinada a seu consumo pessoal.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, ressaltando a divergência entre o interrogatório na fase policial e em juízo, com a valoração na fixação da pena da reincidência e da causa de aumento, com regime inicial fechado. E a defesa técnica, a absolvição do acusado ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime do artigo 28, com aplicação da confissão.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 44/49 e 50/58.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações das testemunhas em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de maconha, o que se soma à confissão judicial do acusado neste particular (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Contudo, segundo se crê, não há prova suficiente no sentido de que o destino da droga apreendida não fosse o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

No caso, a quantidade de droga apreendida não é de todo incompatível com o que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, e, negados os fatos pelo acusado, nem mesmo dos depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela prisão em flagrante se extraí elementos indicativos da destinação a terceiros.

Com efeito, o agente penitenciário André disse que o alarme do presídio foi acionado em razão de pacotes serem arremessados para dentro do pavilhão. Os agentes desceram para recolher os pacotes e evitar que os presos pegassem e realizada revista durante a transferência dos detentos. Em revista, motivada por RAFAEL estar com cobertas em torno de seu corpo, encontrou com RAFAEL a droga. Informalmente, RAFAEL nada disse. A droga estava nas mãos dele. Notou algo estranho diante das vestimentas, da blusa feita de cobertor no momento em que era transferido de

pavilhão. RAFAEL tirou sua roupa sempre com as mãos fechadas até o momento em que o depoente mandou expressamente que ele as abrisse, quando localizou a sacola. Os pacotes arremessados eram aparelhos celulares e não a droga. A roupa era desautorizada, feita pelos detentos. Ia fazer a revista no pavilhão 4, para onde arremessados os ilícitos, daí a transferência de RAFAEL para o outro pavilhão. O agente penitenciário Gersoniel disse que foi iniciada uma revista no pavilhão 4, onde RAFAEL e outros dois rapazes foram flagrados com entorpecente. Estava próximo e Oze, o diretor de disciplina, deu o flagrante. Parece que RAFAEL estava com a droga por debaixo da blusa e foi conduzido à segurança e à Delegacia. Não sabe como estava envolvida a droga, mas era mantida dentro da bermuda, por debaixo da blusa. Estavam todos fazendo a revista dos presos na saída de um pavilhão para o outro. Quando Oze flagrou a droga com o rapaz, apresentou para o depoente.

E, embora tenha negado inicialmente sequer portar a droga, o conteúdo do interrogatório na fase policial não é de todo incompatível com o consumo pessoal se, desde então, se diz usuário de maconha.

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça em caso de todo semelhante envolvendo flagrante de quantidade não exorbitante de droga em estabelecimento prisional, “entendo que é caso de desclassificar a conduta para porte de entorpecentes para consumo próprio. Com efeito, nada há nos autos que permita concluir que os entorpecentes apreendidos se destinavam à entrega a terceiros. A droga era de natureza única e foi encontrada em quantidade que, embora não fosse ínfima, também não era elevada (menos de 30g). Por outro lado, os agentes penitenciários não noticiaram qualquer ato de traficância e a acusação não trouxe aos autos qualquer prova de que, uma vez que ingressasse no estabelecimento prisional com os entorpecentes, o acusado não os utilizaria para seu próprio consumo. Portanto, tendo em vista a situação de evidente incerteza quanto à efetiva destinação dos entorpecentes, o ordenamento jurídico demanda seja solucionada a questão em favor do acusado, conforme o brocardo *in dubio pro reo*.” (Apelação 1500021-22.2022.8.26.0618, Rel. Amable Lopez Soto, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 26/10/2022).

No mesmo sentido, ressaltando a insuficiência, por si só, do depoimento de agente penitenciário quanto a confissão informal da traficância: “também não restou devidamente demonstrada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Afinal, o acusado foi surpreendido no interior de estabelecimento prisional, portando um frasco de maconha (1,57 g) e seis porções de cocaína (2,52 g), conforme se verifica pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo laudo de constatação (fls. 11/14), e pelo exame químico toxicológico (fls. 58/60). Contudo, as provas orais coligidas em juízo não são suficientes para demonstrar a traficância realizada pelo acusado, respaldada tão somente nos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, os quais supostamente obtiveram a informação, pelo próprio réu, de que as porções de cocaína apreendidas seriam destinadas à comercialização. Ocorre que, no caso concreto, o acusado não foi flagrado comercializando os entorpecentes, tampouco em movimentação típica de traficância, fatores que, somados à sua negativa em juízo e à ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, fundamentam a versão de que tais drogas eram destinadas a seu consumo próprio. Em suma, as dúvidas acerca da dinâmica dos fatos reclamam a desclassificação da conduta anteriormente imputada para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade ínfima de entorpecentes, indicam ser o réu mero usuário de drogas.” (Apelação 1501458-18.2021.8.26.0559, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 23/08/2022).

Em suma, a este respeito, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto a este aspecto da responsabilidade penal do acusado. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão neste particular.

Adequação Típica

Como se disse, o quadro probatório evidenciou que o acusado praticou, de forma

consciente e deliberada, a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal, nos exatos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Daí porque, nos termos do artigo 383, caput, do Código de Processo Penal, acolho em parte a pretensão acusatória e atribuo qualificação jurídica diversa à denúncia para reconhecer a prática do crime de porte para consumo pessoal.

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Observo que não há incompatibilidade entre o preceito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a Constituição Federal, mesmo que sob o pálio do princípio da alteridade. Não há dúvida de que o direito penal deve observar se nortear pelo princípio da alteridade ou transcendentalidade, mas o que é observado por esta norma penal, que não pune o consumo de drogas, mas o seu porte com destino ao consumo pessoal, assim com potencialidade de circulação, gerando um perigo à saúde pública.

Incide a agravante da reincidência, nos termos dos artigos 61, inciso I, e 63 do Código Penal, cuja constitucionalidade já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (RE 453000, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013).

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, com as particularidades inerentes às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte

Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As circunstâncias, porém, são graves, porque cometido o crime no interior de unidade prisional, colocando em potencial risco a saúde dos demais internos, já em posição fragilizado pelo cárcere. Não por outro motivo é que os delitos dos artigos 33 a 37 da Lei 11.343/06 contam com causa de aumento específica nesta particular.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social, desfavoráveis as circunstâncias e neutras as demais circunstâncias.

É de rigor, ainda, a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal).

Assim, necessária e adequada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Via de regra, realmente inviável a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Contudo, excepcionalmente na hipótese vertente, em que a sanção penal ao final aplicada é a de prestação de serviços à comunidade – e cujo descumprimento leva, em último caso, à imposição de multa –, impõe-se desde logo reconhecer a extinção da punibilidade pelo seu cumprimento por força da detração, diante do tempo de prisão, no regime fechado da preventiva, em razão deste processo.

Contabilizo, analogicamente, o equivalente a 1/3 do prazo da prestação de serviços em comparação ao tempo da prisão preventiva, assim cumprida a pena 1 mês após o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar RAFAEL MENDONÇA CARIBE à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, pela prática do crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Em razão da detração, julgo extinta desde logo a punibilidade pelo cumprimento da pena imposta em 23 de julho de 2022.

Por consequência, revogo a prisão preventiva antes decretada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; e expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso.

Comunique-se ao juízo da execução criminal respectivo.

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga

guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, cumprida a sanção penal de advertência, por escrito, com a intimação pessoal desta sentença, fica extinta a punibilidade respectiva. Anote-se e archive-se definitivamente.

Int.

Mongaguá, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA